

1502324-92.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1502324-92.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502324-92.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318802/2021 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21556909 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3129/21/126 - 06º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2318802 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SANTOS CALISTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

BRUNO SANTOS CALISTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 10h52min, na Rua das Pétalas, altura do nº 100, bairro Montanhão, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, trazia consigo, no interior de uma sacola, para fins de traficância, drogas consistentes em: a) 153,29g de Tetrahydrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, divididos em 70 invólucros plásticos do tipo "filme"; b) 64,82g de cocaína, fracionados em 100 invólucros plásticos; e c) 26,1g de cocaína na forma de crack, acondicionados em 120 microtubos plásticos do tipo eppendorf, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação a págs.19/21 e químico-toxicológico às págs.53/55. Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares realizavam diligência de rotina quando foram acionados para apurar a ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao local dos fatos, observaram dois indivíduos na via pública, na entrada de uma viela, um dos quais o acusado Bruno, que segurava uma sacola plástica.

O comparsa, ao avistar a viatura, gritou avisando a presença policial e se evadiu correndo. Bruno, entretanto, lançou a sacola para o alto e tentou correr, mas foi abordado pelos policiais militares, que conseguiram detê-lo.

No interior da sacola que Bruno portava, os policiais encontraram 70 porções de maconha, 100 porções de cocaína e 120 porções de crack.

Na Delegacia de Polícia, Bruno confessou a prática do delito (pág. 13). Considerando a elevada quantidade, variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros), assim como as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, que envolveu tentativa de fuga diante da presença dos policiais militares, não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a (págs.04/42). Notificado (pág. 70), o réu ofertou defesa preliminar (pág.73) Recebida a denúncia a (págs.75/76), o réu foi citado (pág. 83). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, aplicando-se o §4º do artigo 33, da Lei de Tóxicos e fixando-se regime aberto para início de cumprimento de pena. A defesa requer a absolvição por ocorrência de coação moral irresistível ou, ainda, insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão de págs. 08/09 e nos laudos de constatação às págs.19/21 e químico-toxicológico às págs.53/55.

Quanto à autoria, nas duas etapas da persecução penal o acusado confessou a prática delitiva:
"Foi convidado a trabalhar na venda de drogas na biqueira situada no local dos

fatos, e na data de hoje acabara de chegar, acompanhado de outro indivíduo cuja qualificação e endereço não sabe informar, mas que o ajudaria na venda das drogas; que já aguardava a chegada dos clientes quando surgiram policiais militares, e o companheiro ao avistar os policiais empreendeu fuga, mas o interrogando não conseguiu fugir, com medo, e permaneceu no local; que junto ao interrogando, os policiais encontraram as drogas, ou seja 100 envelopes de cocaína, 120 pinos de crack e 70 papelotes de maconha" (pág. 13).

Em Juízo, o acusado ofereceu retratação, apresentando dinâmica diversa: Passava por dificuldade financeira e contraiu dívida com traficantes do local para sustentar a família. Para quita-la, os credores o coagiram a transportar uma sacola contendo droga na data do fato. Indivíduo o guiava quando ocorreu a abordagem policial.

A retratação da confissão policial não produz efeitos por si mesma. Cumpre ser acompanhada de provas elidentes, o que não se vê patenteado na espécie.

Nessa linha:

"É necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na Delegacia ou em Juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências"(Rel. CORRÊA DE MORAES - RJTACRIM 43/144).

"De regra, a prova constante no inquérito policial não deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito ocorre sob clandestinidade. As confissões nele obtidas regularmente e estando os seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos têm alto valor probante, devendo ser aceitas, se não elididas na fase judicial" (Rel. GONÇALVES SOBRINHO - JUTACRIM 32/265).

Ademais, a prática do delito pelo acusado vem demonstrada pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Guilherme Lemos da Silva e João Henrique Ferreira da Cruz Silva, em relato coeso e harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência que realizaram na data dos fatos e espcaram qualquer dúvida quanto à autoria:

Embora o local do fato seja conhecido ponto de tráfico de droga, dirigiram-se para lá a fim de averiguar ocorrência de violência doméstica. Enquanto procuravam o imóvel, depararam-se com dois indivíduos na via pública, na entrada de uma viela, um dos quais o acusado Bruno, que segurava uma sacola plástica.

O comparsa de Bruno, ao avistar a viatura, fugiu correndo. Bruno lançou a sacola para o alto e também tentou fugir correndo, mas foi logo detido sem que o perdessem de vista.

A sacola que o acusado dispensou foi apreendida e, dentro dela, foram localizadas porções individuais de drogas de diversa natureza, sendo invólucros e pinos contendo maconha, cocaína e crack.

O policial João Henrique acrescentou que, inquirido, o réu admitiu a autoria da mercancia ilícita.

Não o conheciam antes da abordagem relatada.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Neste sentido:

“Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.^a T., DJe 26/10/2018)

É certo que as testemunhas não recordaram alguns detalhes da diligência. Ocorre que pequenos esquecimentos em pontos não relevantes são compreensíveis em razão do tempo decorrido entre os fatos e a oitiva em Juízo, bem como pelo número de diligências das quais os policiais participam.

Ainda nessa quadra, cumpre anotar que se as testemunhas são concordantes no essencial, o que ocorreu no caso em testilha, eventual esquecimento de pontos secundários não é mal, porque reveste os depoimentos de credibilidade.

Se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada (Rel. CORRÊA DE MORAES – RJTACRIM 33/82). Inexiste o mínimo indicio de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16.^a Câ. Crim., julgado em 27/01/2015).

A ausência de qualificação de civis como testemunhas, por si só, não leva à absolvição do agente, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (70 invólucros plásticos de maconha, 100 invólucros plásticos contendo cocaína e 120 microtubos contendo crack), a forma como acondicionada (individualmente), o local da prisão (conhecido ponto da mercancia ilícita) e as circunstâncias da prisão tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, cumpre anotar, outrossim, que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga a usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo

variado, consoma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta, o réu declarou dificuldade financeira e coação moral. Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminoso foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminoso como meio de vida.

Inexiste nos autos prova de que o agente agiu para se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente, não se desincumbindo, portanto, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Eventual dificuldade financeira não autoriza, por si só, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las.

Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminoso. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

Por derradeiro, também não demonstrada os autos a ocorrência de coação moral irresistível (o réu alegou que devia aos traficantes após contrair empréstimo para sustentar a família).

Segundo a doutrina, a coação existe quando há o emprego de força física ou de grave ameaça para sujeitar o sujeito à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não exigibilidade de conduta diversa.

Na coação moral - tese defensiva - existe a ameaça, de modo que a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor, não lhe sendo exigível comportamento diverso.

Em qualquer hipótese, porém, exige o art. 22 do Código Penal, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, ou seja, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar.

Portanto, é indispensável que no caso concreto se examinem as condições de resistibilidade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como suas condições pessoais (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, Atlas, 7ª Ed., p. 105/106).

No caso em tela não ficaram demonstrados os requisitos legais de tal dirimente, que não encontra respaldo em qualquer elemento de prova carreado aos autos, ônus que incumbia ao réu (CPP, art.156) e do qual não se desincumbiu a contento.
A propósito:

“A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, resumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal” (RJTACRIM 55/78).

“Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação dos réus, especialmente quando a descrição dos fatos por eles fornecida encontra-se rebatida por prova em contrário” (TACRSP, RT 813/596).

“A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, presumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal” (RJTACRIM 55/78).

Aliás, como bem apontado pelo Ministério Público, a tese defensiva não convence. A par do confuso relato do acusado, fato é que os traficantes não necessitariam de sua participação no transporte da droga se o próprio réu declarou que havia alguém apto a fazê-lo.

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Não há agravantes e atenuantes a considerar.

Não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O réu preenche todos os predicados legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

Todavia, há óbice à aplicação do índice redutor máximo.

Com efeito, não é possível olvidar a razoável quantidade de droga - de natureza diversa - apreendida - 290 porções (70 invólucros plásticos de maconha, 100 invólucros plásticos contendo cocaína e 120 microtubos contendo crack).

O benefício de redução de pena previsto no mencionado §4º não foi instituído pelo

legislador para atuar como redutor máximo automático das sanções correspondentes ao tráfico de droga no grau máximo. Teve o escopo de disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento de individualizar as reprimendas correspondentes a esse delito.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou “qualidade”) e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.

Assim, pelas razões alhures, reduziu a pena em 5/12, o que perfaz 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado.

A jurisprudência majoritária acolhe o entendimento de que tais circunstâncias devem ser apuradas nesta etapa da dosimetria da pena, método compatível com a melhor hermenêutica e mais próximo da correta interpretação e aplicação do Direito como ciência (Apelação Criminal nº 0003571-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 11/05/2010; Apelação Criminal nº 0074313-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/08/2011; Apelação Criminal nº 0011319-96.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/10/2012).

Ainda nessa linha:

AgRg no HC 209930/ES, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgado em 18/10/2012; HC 244726/ES, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/10/2012.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o aberto.

Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e

a não reincidência.

Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”) trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)”

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º (“tráfico privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”.

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber:

A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto.

Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes

criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas. Confessou a prática do crime. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Cumpre-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Na espécie, o réu portava quantidade razoável de droga. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do inculpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína.

O crime é de perigo abstrato.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado BRUNO SANTOS CALISTO DA SILVA, qualificado às págs.22/25, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

O réu respondeu ao processo preso, convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (págs.29/32).

Diante da pena e regime aplicados, o réu poderá recorrer em liberdade, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Decreto o perdimento do dinheiro, oriundo do tráfico de droga, bem como da pochete usada no crime em favor da União.

De imediato, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência administrativa;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA